

1500222-29.2022.8.26.0613

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME MARTINS DAMINI

Comarca: Santa Cruz das Palmeiras

Foro: Foro de Santa Cruz das Palmeiras

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 10/08/2022

... outros crimes graves relacionados ao narcotráfico, a exemplo do homicídio, do roubo, da corrupção, do tráfico de armas etc. De conseguinte, afigura-se proporcional atribuir-se à reiteração delitiva posterior à condenação definitiva por tal injusto o efeito da reincidência.

Além disso, o delito foi cometido em ocasião de estado de calamidade pública, conforme Decreto Legislativo n. 6 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Cruz das Palmeiras

Vara Única

Avenida do Café, nº 665, Centro, Santa Cruz Das Palmeiras - 13650-000 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Processo nº:

1500222-29.2022.8.26.0613

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2152220/2022, 25379933, 2152220

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO VICTOR DA SILVA BATISTA

Réu Preso

Ao(s) 10 de agosto de 2022, às 14 horas e 15 minutos, nesta cidade e Comarca de Santa Cruz das Palmeiras, sendo realizada, por meio virtual, via videoconferência criada no software Microsoft Teams, sob a presidência do(a) MM(a). Juiz(a) de Direito, Dr(a). GUILHERME MARTINS DAMINI, comigo, Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe.

Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, estiveram presentes na teleaudiência:

O(A) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). SERGIO HENRIQUE MARINO, DD(a). Promotor(a) de Justiça; A(O)(s) ré(u)(s) JOÃO VICTOR DA SILVA BATISTA, acompanhado(a)(s) de seu(s) Defensor(es)(a)(s) constituído(a)(s) Dr(es)(a)(s). Eduardo Rodrigues Azevedo OAB 169779/SP;

A(s) testemunha(s) de comuns Daniel Leone e Wesley Aparecido Vieira.

Após, antes do início dos trabalhos, o(a)(s) advogado(a)(s) de Defesa solicitou(ram) comunicação privada com a(o)(s) ré(u)(s). O que foi deferido pelo MM(a). Juiz(a), a título de entrevista prévia ao seu interrogatório, determinando que todos saíssem da sala virtual. Pelo Ministério Público, nada foi requerido.

Iniciados os trabalhos, pelo(a) MM(a). Juiz foi dito: "Nos termos da Súmula Vinculante nº 11, do Egrégio Supremo Tribunal Federal, caso a(o) ré(u) esteja

recolhido(a) em estabelecimento prisional e se senta em lugar com possíveis falhas de guarnição, em momento de sensível receio a fuga ou de perigo à integridade física dos policiais penais que ali trabalham, mantém-se justificada a não-retirada das algemas, preservando-se assim, a higidez do ato e a normalidade dos trabalhos. Saliente-se que, o uso ou não de algemas será decidido, conforme o caso, pelos policiais penitenciários locais que guarnecem as salas de teleaudiência da penitenciária. Ordem resguardada por procedimento geral de segurança, adotado pela autoridade policial local, responsável pelo estabelecimento, visando a perfeita ordem na realização de teleaudiências, pois sabem das eventuais falhas de segurança na penitenciária e/ou da(s) periculosidade(s) do(a) ré(u), presente na solenidade, por meio de comportamento(s) inadequado(s) durante o cumprimento de sua(s) pena(s). Além disso, nos termos da resolução 465 de 2022, do Conselho Nacional de Justiça, zelando pela adequada identificação e vestimenta que a solenidade requer, alerta ao(a)s Advogado(a)s e o(s) membro(s) da Defensoria Pública e do Ministério Público da necessidade de utilização de terno ou toga, permanecendo com a câmera ligada, em condições satisfatórias e em local adequado durante toda sessão.". Em seguida, pelo(a) MM(a). Juiz(a), foi(ram) colhido(s) o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) Daniel Leone (início do vídeo). A imagem, deste vídeo, não apareceu na gravação por motivos técnicos de gravação e/ou conexão do próprio software Microsoft Teams pois os presentes conseguiram ver e ouvir a testemunha, esse erro só foi constatado após a gravação ter sido finalizada. Pelo Ministério Público e pela Defesa foi requerido a desistência na oitiva da testemunha Wesley Aparecido Vieira, sendo esta desistência homologada pelo MM(a). Juiz(a).

Em seguida, foi(ram) feito(s) o(s) interrogatório(s) da(o)(s) ré(u)(s) JOÃO VICTOR DA SILVA BATISTA (04:27).

O(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) pelo sistema Microsoft Teams, informando-se os presentes sobre as gravações e com os tempos de gravação indicados no formato (Horas:Minutos:Segundos) em cada depoimento presente neste termo ou indicados por vídeos próprios.

Ao final, pelas partes, foi dito que não haviam requerimentos de diligências a serem apresentados e/ou provas a serem produzidas. Sendo assim, deliberou o(a) MM(a). Juiz(a): "Vistos. Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução e determino às partes que apresentem suas alegações finais.". Dada a palavra ao Ministério Público e a Defesa, suas alegações finais orais foram gravadas pelo sistema Microsoft Teams e armazenadas no sistema SAJ junto com a prova oral colhida em audiência.

Na sequência, pelo(a) MM(a). Juiz(a), foi proferida a seguinte sentença:

"Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público contra JOÃO VICTOR DA SILVA BATISTA, qualificado. Narrou a denúncia que, no dia 4 de junho de 2022, por volta das 19h30, na Rua Treze de Maio, altura do nº 496, Jardim Santa Terezinha, nesta comarca, o acusado trazia consigo, para fins de tráfico, 15 porções de cocaína, com peso bruto de 12,23 gramas, substância causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Pugnou, assim, pela condenação às sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 39/42).

Notificado, em defesa prévia, sem preliminares, o acusado se reservou no direito de se manifestar sobre o mérito em alegações finais. Arrolou as mesmas testemunhas da acusação (fls. 111/112).

A denúncia foi recebida em 11/07/2022, designando-se audiência de instrução (fl. 116).

Ao longo da instrução, foi ouvida 1 (uma) testemunha e interrogado o acusado. A

testemunha Wesley Aparecido Vieira foi dispensada pelas partes, o que foi homologado.

Na fase do art. 402 do CPP, nenhuma diligência foi requerida.

Por meio de alegações finais orais, o Ministério Público reiterou os termos da inicial acusatória e requereu a condenação do acusado.

Por sua vez, a Defesa pugnou pela fixação da pena no mínimo legal, reconhecendo-se a atenuante da confissão espontânea, concedendo-lhe a benesse do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em regime inicial aberto, com direito a recorrer em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decidido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Inexistindo nulidades a inquinar o feito, e estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, examino o mérito.

A materialidade dos fatos promana do auto de prisão em flagrante (fl. 1), boletim de ocorrência (fls. 12/14), auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), auto de constatação preliminar (fl. 19), laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 135/137), bem como da prova oral colhida.

A autoria é certa e deve ser atribuída ao acusado, a qual a confessou integralmente, o que foi corroborado pelos depoimentos colhidos ao longo da persecução criminal.

Com efeito, o militar Daniel Leone, em juízo, aduziu que durante o patrulhamento preventivo pela cidade, ao passar por um local conhecido como ponto de venda de drogas, avistou o acusado promovendo o tráfico de drogas pela via pública, aparentemente servindo um usuário, aproximando para abordagem; durante a aproximação, o suposto usuário correu em sentido oposto enquanto o outro indivíduo permaneceu no local, realizando sua abordagem; ao proceder a revista pessoal do réu, já conhecido pelo envolvimento com o tráfico de entorpecentes na cidade, localizou em seu poder 15 eppendofs contendo cocaína e a quantia de R\$140,00 (cento e quarenta reais), em notas trocadas; indagado, o abordado confessou informalmente a autoria do crime, afirmando que o entorpecente localizado em seu poder seria destinado a venda; o indivíduo não aparentava estar drogado e nenhum objeto para consumo foi encontrado; já era conhecido o indivíduo por tráfico.

A testemunha Wesley Aparecido Vieira, também policial, ouvido apenas no inquérito, corroborou o aduzido pelo colega de farda, depondo em semelhante sentido.

Nada nos autos aponta no sentido de que os deponentes tiveram o intuito espúrio de incriminar o agente indevidamente, o que não decorre automaticamente da circunstância de se cuidar de policiais militares. Até porque prestaram depoimento sob o compromisso do art. 203 do CPP, razão pela qual o quanto por eles aduzido merece relevo para fins de formação do convencimento decisório. A jurisprudência é pacífica sobre o tema:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação policial, age facciosamente, ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.” (STF, HC 74.608-0/SP, Min. Celso de Mello, j. 18.2.97, apud JTJ 263/518)

As drogas não se destinavam ao exclusivo consumo pessoal. É o que deflui da análise em concreto dos parâmetros estabelecidos pelo art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06.

Afinal, foram apreendidos entorpecentes de alto potencial ofensivo (cocaína), que estavam embalados para venda. Além disso, foi apreendido dinheiro trocado, circunstância típica de transações comerciais, em que o troco se faz necessário.

Não bastasse, o indivíduo não aparentou estar drogado como um mero consumidor ali presente, até porque nenhum objeto para utilização foi achado, o local da apreensão é palco comum deste tipo de delito, o acusado é conhecido nos meios policiais e presenciou-se ele servindo terceiro, possível comprador. Tudo isso reflete o propósito de difusão ilícita, o qual não é excluído, por si só, pela eventual

concomitante condição de usuário regular de drogas.

Bem por isso, ficou claro que o denunciado, de forma consciente e intencional e, portanto, dolosa (art. 18, I, CP), trouxe consigo drogas, com finalidade mercantil, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O fato, pois, é típico, por se amoldar à conduta descrita no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

A ilicitude é patente, à luz da teoria indiciária ou da ratio cognoscendi, porquanto não há quaisquer eximentes.

Também se faz presente a culpabilidade. Isso porque o réu é imputável, tinha potencial consciência da ilicitude e dele era exigível conduta diversa, nenhuma dirimente militando em seu favor.

Nesse cenário, observada a harmonia e a coesão do conjunto probatório, não há qualquer incongruência ou dúvida relevante que pudesse atrair a incidência do in dubio pro reo, corolário do princípio da presunção de inocência (art. 5º, XLVI, CF/88).

Destarte, sendo o fato típico, ilícito e culpável, de rigor a condenação.

II.1 – DOSIMETRIA DAS PENAS

Passo, pois, à dosimetria e individualização das penas (art. 5º, XLVI, CF/88), norteando-me, precipuamente, pelos arts. 59 e 68 do CP e art. 42 da Lei 11.343/06.

A culpabilidade, assim entendido o grau de reprovabilidade, é normal à espécie. Os antecedentes serão valorados na segunda fase, para evitar-se o bis in idem. A conduta social, caracterizada pelo comportamento no meio em que vive, a personalidade, que representa a índole do agente, e os motivos, consubstanciados pelas razões delitivas, não contam com elementos suficientes para esclarecimento. As circunstâncias, dados periféricos da prática criminosa, que abrangem a natureza e a quantidade das drogas, são negativas, ao passo que envolvem cocaína, droga de alto potencial ofensivo. As consequências, as quais correspondem ao mal causado pelo delito que transcende o resultado típico, não foram graves. O comportamento da vítima, toda a coletividade, é neutro e não o desfavorece.

Na primeira fase, 1 (uma) circunstância valorada negativamente, fixo as penas-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, presentes as atenuantes da menoridade relativa (art. 65, I, CP), por se tratar o agente de menor de 21 (vinte) e um anos na data do fato (fl. 22), a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP), a agravante da reincidência (art. 61, I, CP – condenação transitada em julgado em 03/06/2022, pelo crime do art. 28 da Lei 11.343/06, praticado em 2021 – 1500262-42.2021.8.26.0129 – consulta ao inteiro teor – fl. 197 (fls. 133/134) e a agravante do art. 61, II, “j”, CP, as compenso e mantenho as sanções.

Destaco, no ponto, que, malgrado o fato previsto no art. 28 da LD não desafie a aplicação de pena privativa de liberdade, possui natureza jurídica de crime, o que reconhece o Supremo Tribunal Federal (RE 430.105 QO/RJ), razão pela qual é apto a configurar a reincidência, na forma do art. 63 do CP. Respeitada a posição diversa, entender em contrário implicaria em derogar o alcance deste dispositivo legal, que possui natureza cogente e de ordem pública. O expediente, contudo, somente é deferido ao Poder Legislativo, sob pena de violação aos princípios da separação dos poderes, da legalidade (art. 2º e 5º, XXXIX CF/88) e da justeza ou conformidade funcional, o qual impede que, por via da hermenêutica, pelo senso pessoal de justiça do julgador, seja desvirtuado o esquema organizatório constitucionalmente estabelecido, no que concerne à repartição de funções.

Afinal, a brandura com que o delito em análise foi apenado (advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo) reflete nada mais que certa complacência do legislador, fundada no pensamento impreciso e incompleto de que o usuário não passa de um doente, vítima de dependência química. A prática, porém, possui potencial ofensivo nada desprezível e superior ao das contravenções penais, porquanto lastreia diretamente todo o comércio ilegal de drogas e, com ele, diversos outros crimes graves relacionados ao narcotráfico, a exemplo do homicídio, do roubo, da corrupção, do tráfico de armas etc. De conseguinte, afigura-se proporcional atribuir-se à reiteração delitiva posterior à condenação definitiva

por tal injusto o efeito da reincidência.

Além disso, o delito foi cometido em ocasião de estado de calamidade pública, conforme Decreto Legislativo n. 6 do Congresso Nacional e Decreto n.º 64.879 do Estado de São Paulo, ambos em vigor em 20/03/20, assim permanecendo até presente data. Trata-se de circunstância objetiva, cuja incidência deve se dar em razão da maior vulnerabilidade da saúde pública que, nem mesmo assim, foi óbice para que o réu cometesse o delito. Não se pode olvidar que a presente causa de exasperação da pena não se justifica apenas na hipótese em que o agente se vale da calamidade para praticar o delito. Ora, tal tem lugar, outrossim, em razão da maior reprovabilidade do fato praticado em meio ao caos sanitário provocado pela COVID-19, em que os recursos e esforços estatais devem ser focados no combate à pandemia – e não na persecução penal de delinquentes – em prol da preservação da vida e da saúde da população, bens jurídicos dos mais caros à proteção a ser conferida pelo Direito Penal. Nessa linha: TJSP; Apelação Criminal 1510850-88.2020.8.26.0050; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 27ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/02/2021; Data de Registro: 03/02/2021.

Na terceira fase, inexistindo quaisquer minorantes e majorantes, concretizo-as sem alterações.

É descabida a aplicação do privilégio, porquanto não preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, por se tratar de reincidente e pessoa dedicada a atividades criminosas, observado o extenso histórico infracional por ele ostentado, com destaque para a circunstância de ter cumprido medida socioeducativa por ato infracional análogo ao tráfico (fl. 128).

Fixo o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo vigente ao tempo do fato, tendo em conta a ausência de informações sobre a condição econômica do réu (art. 49, § 1º c/c art. 60, CP).

O regime inicial será o semiaberto, ante o patamar de pena corporal aplicado (art. 33, § 2º, “b”, CP).

Embora trate-se de crime equiparado ao hediondo, o art. 2º, § 1º da Lei 8.072/90, afigura-se inconstitucional, por desrespeito ao dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF) e ao princípio da individualização das penas (art. 5º, XLVI, CF) (HC 111.840, STF).

Inviável a aplicação do art. 387, § 2º, do CPP, por falta de informações hábeis a respaldar não só a real situação processual do acusado, mas também os requisitos subjetivos indispensáveis à estipulação de regime diverso do ora imposto, cabendo-lhe pleitear o benefício que entende devido junto à Vara de Execução Criminal Competente.

Não é cabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, em virtude da quantidade de aplicada (arts. 44 e 77, CP).

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedente o pedido constante da exordial, resolvendo o mérito, para CONDENAR o réu JOÃO VICTOR DA SILVA BATISTA, qualificado nos autos, com fulcro no art. 387 do CPP, pela prática do crime previsto no art. 33, caput Lei 11.343/06, a 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

IV – DELIBERAÇÕES FINAIS

Deixo de fixar valor mínimo para reparação do dano causado pelas infrações, na forma do art. 387, IV, do CPP, ao passo que não houve requerimento por parte do Ministério Público, o que inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado (art. 5º, LV, CF/88).

Indefiro o recurso em liberdade, ao passo que subsistem os motivos que ensejaram a segregação cautelar, em prol da ordem pública, tendo em vista o risco de reincidência, oriundo da reiteração criminosa verificada (trata-se de reincidente e com diversas passagens pela Justiça da Infância e da Juventude em razão de atos infracionais – fls. 128, 129/130), que indica que faz do crime seu meio de vida, à luz dos art. 282 c/c art. 312 c/c art. 313 c/c art. 387, §1º, do CPP.

Registro, no ponto, que, segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de

Justiça, não há incompatibilidade entre a manutenção da segregação provisória e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do apenado com as regras próprias desse regime (STJ, AgRg no HC 640.933/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021).

Recomende-se a manutenção do réu na prisão em que se encontra e, havendo recurso, expeça-se guia de execução provisória, oficiando-se à VEP, observadas as diretrizes de compatibilização da prisão cautelar do apenado com as regras próprias do regime semiaberto, nos termos da fundamentação retro.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais (art. 804, CPP). Eventual requerimento de gratuidade da justiça será analisado na fase de execução.

Após o trânsito em julgado: a) oficie-se ao Instituto de Identificação, na forma da lei; b) oficie-se ao TRE, para fins do disposto no art. 15, III, da CF/88 c/c art. 71 do Código Eleitoral; c) expeça-se guia de execução definitiva (art. 106, LEP); d) determino a destruição das amostras de drogas guardadas para contraprova, com certificação nos autos (art. 72, Lei 11.343/06); e) decreto o perdimento da quantia em dinheiro apreendida, enquanto produto do crime (art. 91, II, "b", CP c/c art. 122, CPP); f) se o caso, determino o pagamento de honorários ao (à) patrono (a) dativo nomeado (a), em valor proporcional aos serviços prestados, a critério do órgão pagador (DPE/OAB), expedindo a serventia o necessário; g) oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Dispensado o registro (Provimento CG n. 27/2016)."

A sentença foi lida aos presentes que saíram devidamente intimados. Pela(o) ré(u) e pelo(a) o(a)(s) Advogado(a)(s) de Defesa foi interposto recurso de apelação, neste ato, recebido pelo(a) MM(a). Juiz(a), saindo a Defesa intimada para apresentar razões no prazo legal. Após, intime-se o Ministério Público para apresentar as contrarrazões do recurso, no prazo legal. Ao final, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as cautelas necessárias e homenagens deste juízo. O Ministério Público manifestou desejo de não recorrer, operando-se o trânsito em julgado para a acusação nesta data, valendo a presente como certidão.

Não havendo óbice na utilização de sistema de videoconferência em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por esse sistema e juntados aos autos no sistema SAJ. NADA MAIS, para constar lavrei o presente termo de audiência. Dispensada a assinatura das partes por se tratar de processo eletrônico. Eu THAUANN PINHEIRO SANTIAGO, Escrevente Técnico Judiciário, M373043, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA